

일의 대가

— ‘시간당 소정임금’ 산정가능성과 그 의미 —

장 우 찬*

목 차

- I. 서론
- II. 시간당 일의 대가 산정 - 시간당 소정임금의 계산
- III. 논의의 실익과 한계
- IV. 결론

I. 서론

2013년도 전후로 시작하여 최근까지 통상임금과 관련된 논의가 붓물처럼 쏟아져 나왔다. 통상임금의 구성항목과 산정문제는 마치 블랙홀과 같아서 노동관계의 다른 논의를 할 겨를도 없이 주변부 논의들을 빨아 들여왔다. 더군다나 통상임금의 개념정의나 대상범위에 대한 법률의 규정 없음이 문제를 더 확대시키기도 하였다. 당해 주제에 관해서는 너무나 많은 논의들이 있어 왔으므로 이 글에서는 다른 시각과 주제로 노동의 대가인 임금에 대해서 다루어 보고자 시도하였다.¹⁾ 그럼에도 불구하고

투고일 2018. 8. 20, 심사일 2018. 9. 5, 게재확정일 2018. 9. 10.

* 경남과학기술대학교 인문사회과학대학.

1) 통상임금이나 최저임금을 주제로 한 관련 논문들을 당해 논문에서는 지면상 모두 언급할 수 없는 관계로 이하에서는 직접적으로 인용하고 있는 논문이나 저서들만 적시하고 있음을 양해 바란다.

이 글 역시 통상임금 문제와 관련됨을 부인할 수 없다. 특히나 통상임금과의 비교와 대조는 피하기 어려웠다. 다만, 최대한 통상임금 관련 세부 쟁점에 대한 천착과 기존 논의방식의 답습을 피하면서 논지를 전개하고자 노력하였다. 더불어 기존에 익숙한 법학적 연구방식 대신에 가상의 도출과정방식을 시도하였다. 오로지 합리성 여부만이 이러한 논의과정의 타당성을 담보해 줄 것이다.

지난 근로기준법 개정 때 필자 개인적으로 재미있다고 여겨지는 법률 규정 하나가 신설되었다. 근로기준법 제2조 제1항 제7호가 바로 그것이다. 이 조항은 “1주란 휴일을 포함한 7일을 말한다.”고 규정하고 있다. 너무도 당연한 내용이어서 당해 법조항을 볼 때마다 이것이 법률로 규정되어 있다는 사실이 어색하게 느껴진다. 그러나 당해 규정은 지금까지 근로시간과 관련하여 규범과 현실이 괴리되어 있어 왔다는 것을 반증하며, 동시에 앞으로도 이러한 경우가 얼마든지 발생할 수 있다는 것을 경고한다.²⁾ 그렇다고 모든 당연한 사실들을 법률로 세세하게 규정할 수도 없을

2) 근로시간뿐만 아니라 임금과 관련하여 모호한 규정은 근로기준법 도처에 산재해 있다. 근로기준법 제55조의 주휴일과 관련하여 “사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다.”고 규정하고 있다. 이 경우 유급의 경우 주휴수당을 지급해야 하는지 문제된다. 하갑래 교수는 다음과 같이 지적하고 있다. “주당 소정근로시간인 40시간을 어떻게 배분하느냐는 사업장에 맡겨져 있으므로, 유급휴일의 1일 소정근로시간에 대해 평균개념을 사용하여 40/6시간으로 해도 범위반으로 보기 어렵다. 이 경우 주휴수당 등 여러 근로조건에 대해 8시간과 40/6시간을 번갈아 사용하면서 근로자에게 불이익하게 한다면 이는 부당하다. 따라서 어느 쪽이든 하나를 정하여 공통으로 적용하는 것이 타당하다. ...(중략)...공민권행사에 대해서는 관련법에 규정이 있으면 임금이 지급된다. 이 때 관련법의 표현인 ‘휴무 또는 휴업으로 보지 않는다’는 유급 나아가서 통상임금을 의미하는 것으로 해석할 수밖에 없다. 또한 당사자가 유급으로 정하면서 산정기초를 밝히지 않으면 이 역시 통상임금으로 해석할 수밖에 없다. 휴가나 공민권행사처럼 실제로 근로를 제공치 않은 경우, 근로한 것으로 간주할 수는 있지만, 당연히 통상임금으로 해석할 근거는 약하다. 뿐만 아니라 근로를 제공하는 경우에도, 유급의 산정기초를 당사자가 자율적으로 결정하는 것을 인정하는 해석도 있음을 감안하면, 통상임금을 적용해야 한데 대해 강행적 효력을 부여하기 어렵다. 해당 근로조건에 대해 통상임금으로 지급된다는 의미가 명확해지도록 법에 명시하는 것이 바람직해 보인다.”(하갑래, 『근로기준법』 제30판, (주)중앙경제, 2018, 234쪽)

것이다. 그렇다면 이제 필요한 것은 이성에 입각하여 현행의 법률을 체계적이며 논리적으로 해석하는 것이다. 그 시작은 문언적 해석에서 출발한다.

이 글에서는 법률인 근로기준법에서 노동의 대가인 임금과 관련하여 어떻게 규정하고 있는지 살펴보고 이를 중심으로 어떻게 해석하는 것이 타당한지 해석론을 전개한다. 근로기준법 제56조가 바로 그 대상이다. 다만 이 경우에 필자는 관련 내용이 규정되어 있지 않는 것으로 보아 이른바 ‘조리’에 의하여 해석하고자 한다. 조리란 후술하다시피 이성에 근거하므로 규범적인 근거도 제시되지 않은 가상적이고 일방적인 주장이 될 수 있다. 합리성과 타당성에 대한 신랄한 비판을 달게 받지 않을 수 없는 부분이다.

II. 시간당 일의 대가 산정 - 시간당 소정임금의 계산

1. 문제의 소재

가. 근로기준법의 규정

근로기준법 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)

① 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50
2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

근로기준법 제56조 제1항은 “사용자는 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.”고 규정하고 있고 제2항에서는 “제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.”고 규정하고 있다. 제3항에서는 “사용자는 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.”고 규정하고 있다.

근로기준법은 연장근로, 휴일근로, 야간근로 시에 가산하여 지급할 액수를 통상임금의 100분의 50 이상이라고 규정하고 있을 뿐 초과근로를 약정하여 실제 연장 근로한 시간에 대해서는 얼마를 지급하여야 하는지 규정하고 있지 않다. 즉 초과근로한 시간에 해당하는 일의 대가인 임금액수에 대하여서는 규정하고 있지 않은 것이다.

이를 입법의 불비로 볼 것인지, 아니면 조리 즉 이성에 의하여 해결 가능한 것이기 때문에 굳이 규정할 필요가 없었다고 입법자는 생각한 것인지 문제된다. 그렇다면 현재의 관행대로 통상임금으로 계산하는 것이 옳은 것인가? 근로기준법은 통상임금으로 계산하여 지급한다고 명확하게 규정하고 있지 않다. 만약 통상임금으로 지급한다면 현재 시행령상에서 정의내리고 있는 통상임금의 정의가 ‘시간당 노동의 대가’로 적합한지가 먼저 검토되어야 할 것이다. 이 글에서는 기존 통상임금의 정의와 산입 범위에 대한 논의들이 ‘시간당 노동의 대가’로 적합한지 세세하게 검토하는 방식을 취하지 않는다. 대신에 시간당 노동의 대가에 대한 규정이 없으므로 이에 대하여 조리에 근거하여 산정 가능한 것인지 그리고 산정 가능하다면 어떠한 방식으로 산정하는 것이 타당한지 살펴보고자 한다.

나. 문제 상황

연장, 휴일, 야간근로를 할 경우 시간외근로에 대한 대가가 지급되고, 더불어 근로기준법의 규정에 따른 가산수당이 부과되어야 한다. 그렇다면 가산수당 외에 연장, 휴일, 야간근로를 행한 시간만큼의 “근로에 따른 대가는 어떻게 산정될 것인가? 이를 근로기준법에 명문으로 규정하지 않은 것은 굳이 규정하지 않더라도 당연히 도출가능하기 때문은 아닌지 살펴

볼 필요가 있다.³⁾

예를 들어 근로자가 하루 8시간의 근로를 하고 1시간 더 연장근로를 하였을 경우 1시간 연장근로에 대하여 지급하여야 할 액수에 대한 문제이다. 당해 지급액수는 (A)1시간당 임금 + (B)1시간 연장근로로 인한 가산수당이 될 것이다. 이 경우 (B)값은 근로기준법 제56조에 의하여 통상임금을 기초로 하여 산정하는데, (A)값은 어떻게 산정하느냐의 문제이다.

<연장근로 등으로 인한 비용 또는 보상>

시간당 초과근로로 인한 지급액 (A+B)		
구 성	A : 시간당 임금	B: 시간당 연장근로로 인한 가산수당
규정 유무	규정 없음 => 산정문제 발생	통상임금의 100분의 50 이상 가산 (근로기준법 제56조)
용 어	시간당 소정임금	가산수당(할증임금)

2. 시간당 소정임금의 산정

가. 용어의 정리

근로기준법 제2조 제1항 3호는 “근로란 정신노동과 육체노동을 말한다.”고 규정하고 있다. 그리고 동법 동조 동항 제5호에서는 “임금이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.”고 규정하고 있다. 또한 근로기준법 제43조 제2항에서는 “임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 한다.”고 규정하고 있다.

이를 종합해 보면 근로기준법에서 규정한 ‘일의 대가’란 임금을 말하고 사용자가 근로의 대가로 지급하는 명목 불문 일체의 금품을 의미한다

3) 김홍영, “통상임금의 입법적 과제”, 『노동법학』 제48호, 한국노동법학회, 2013, 6쪽에서는 “각각의 기준임금들이 사용되는 입법 목적과 취지에 부합하게 각각의 기준임금들을 재배치하고 그 범위를 정비하는 것이 현실적인 입법론”이라고 제안하고 있다. 시간당 초과근로로 인한 지급액 중 시간당 임금 부분에 있어서 어떤 기준임금을 사용할 것인지에 관해서는 언급이 없다.

고 할 것이다. 그렇다면 일의 대가인 임금은 근로자에게 지급하여야 하는(또는 지급하는) 금품으로서, 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급되어야 하므로 일급, 주급, 월급 등의 방식으로 지급 가능하다.

이때 시간당 일의 대가는 시간당 임금을 의미하는데, 임금은 소정근로에 대한 임금을 대상으로 하기 때문에 이를 명확하기 위하여 이른바 ‘시간당 소정임금’이라 칭하기로 한다. 따라서 이하에서는 시간당 소정임금이라는 용어를 사용한다.

나. 통상임금의 활용에 대한 비판

(1) 판례 및 일반적 해석론

시간당 소정임금에 대하여 판례나 일반적인 해석론으로서는 통상임금을 기초로 하여 지급한다는 견해를 취하고 있다. 대법원은 대법원 2013.12.18. 2012다89399 전원합의체 판결에서 통상임금을 “근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하는 근로의 가치를 금전적으로 평가한 것”이라고 표현하면서 통상임금이 미리 확정되어 있어야 하는 이유를 “사용자와 근로자는 소정근로시간을 초과하여 제공되는 연장근로 등에 대한 비용 또는 보상의 정도를 예측하여 연장근로 등의 제공 여부에 관한 의사결정을 할 수 있고, 실제 연장근로 등이 제공된 때에는 사전에 확정된 통상임금을 기초로 하여 가산임금을 곧바로 산정할 수 있게 되기 때문이다.”라고 하고 있다. 결국 판례는 통상임금을 통상적 근로에 대한 금전적 가치로 보고 있으며 사용자와 근로자 간에 비용 또는 보상의 예측가능성을 담보하기 위한 기능을 한다고 보고 있다. 그러므로 연장근로 등에 대한 비용 또는 보상을 구성하는 시간당 소정근로(앞의 표에서 A 값)도 통상임금으로 해석하고 있다고 평가할 수 있다. 또한 대법원이 통상임금을 기초로 판단하고 있다는 것은 통상임금 산정을 위한 기준시간 선정시 1주의 소정근로시간 수에 유급휴일시간 수를 더한 것을 판단하여 1일의 통상임금 산정 기준시간 수를 판단하는 방식을 취한 것이나,⁴⁾ 그 후에 변경한 유급휴일시간 수 제외하는 방식을 취한 것을 통해 유추할

4) 대법원 1990. 12. 26. 선고 90다카12493 판결.

수 있다.⁵⁾ 대법원은 전자의 판결에서 “월급 통상임금에는 ...(중략)...소정의 유급휴일에 대한 임금도 포함된다고 할 것이므로 월급 통상임금을 월 소정근로시간수로 나누는 방법에 의하여 시간급 통상임금을 산정함에 있어서는 월 유급휴일 해당 근로시간 수도 월 소정근로시간 수에 포함되어야 할 것이다.”라고 하였고,⁶⁾ 후자의 판결에서는 “근로자에 대한 임금을 월급으로 지급할 경우 월급에는 구근로기준법 제45조 소정의 유급휴일에 대한 임금도 포함된다고 할 것이고, 그와 같은 유급휴일에 대한 임금은 원래 소정근로일수를 개근한 근로자에 대하여만 지급되는 것으로서 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금이라고 할 수 없어 통상임금에는 해당되지 않는다고 할 것이어서 통상임금을 산정함에 있어서는 매월 지급받는 월 기본급과 고정수당을 합산한 월급에서 이와 같은 유급휴일에 대한 임금을 공제하여야 한다.”고 하였다.⁷⁾ 이는 “유급휴일에 대한 임금이 통상임금에 포함되는 것을 전제로 한 것”인데⁸⁾ 통상임금 산정을 위한 기준시간 산정시 이를 고려하는 방식이 유급휴일에 대한 임금을 시간으로 환원하여 제(除)하거나 감(減)하는 방식을 취하고 있으므로 유급휴일에 대한 시간당 임금을 통상임금 기준으로 하여 산정하는 것을 전제한다.⁹⁾

학설은 근로기준법 제56조의 해석과 관련하여 다음과 같이 설명하고 있다. “근기법은 연장, 휴일근로에 대해 ‘통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여’라고만 규정하고 정작 해당근로시간의 근로에 대한 임금을 거론하지 않고 있다. ‘통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여’라는 표현은 연장, 휴일근로에 대해 임금의 지급근거가 통상임금이고 이를 기초로

5) 대법원 1998. 4. 24. 선고 97다28421 판결.

6) 대법원 1990. 12. 26. 선고 90다카12493 판결.

7) 대법원 1998. 4. 24. 선고 97다28421 판결.

8) 박은정, “통상임금 산정을 위한 기준시간”, 『노동정책연구』 제13권 제4호, 한국노동연구원, 2013, 139쪽.

9) 통상임금으로 산정해야 시간으로 환산가능하기 때문이다. 예를 들어 통상임금의 100분의 50은 1/2시간으로 환산될 수 있는데, 통상임금을 기준으로 하지 않으면 시간으로 환산이 불가능하다. 이는 이른바 ‘명목근로시간’의 문제라 할 수 있다. 이와 관련하여 더 자세한 사항은 박은정, 위의 글을 참고하기 바란다.

50%를 가산하라는 의미로 확대하여 해석할 수는 있다.”¹⁰⁾

이에 대해 필자는 연장 근로 등에 대해서 해당근로시간의 근로에 대한 임금을 통상임금으로 지급한다고 해석하는 견해와 관련하여 다음과 같은 의문이 있다.

첫째, 통상임금이 1시간당 일의 대가인지 여부가 전제되어야 한다. 이를 위해서는 현재 시행령상의 통상임금의 정의규정이 1시간당 일의 대가로 적합한지가 검토되어야 한다.¹¹⁾ 둘째, 통상임금은 이른바 기준임금 내지 준거임금으로서 근로기준법에서 통상임금을 통해 계산할 수 있는 항목을 한정적으로 규정하고 있다. 셋째, 통상임금의 본질과 통상임금의 기능 사이에는 괴리가 있다. 이에 대해서는 특히 통상임금의 개념 및 그 기능과 밀접한 관계가 있다. 이하에서 설명하고자 한다.

(2) 통상임금의 개념

근로기준법 시행령 제6조 제1항은 “통상임금이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.”고 규정하고 있다. 간략하게 다시 정리하면 “통상임금이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로에 대하여 지급하기로 정한 금액”이라고 할 수 있다.

앞서 살펴본 바와 같이 판례는 통상임금을 “근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하는 근로의 가치를 금전적으로 평가한 것”이라고 하면서, “근로자가 실제로 연장근로 등을 제공하기 전에 미리 확정되어 있어야 할 것”이라 하고 있다.¹²⁾ 그리고 그 이유로 “사용자와 근로자는 소정 근로시간을 초과하여 제공되는 연장근로 등에 대한 비용 또는 보상의 정도를 예측하여 연장근로 등의 제공 여부에 관한 의사결정을 할 수 있고,

10) 하갑래, 앞의 책, 234쪽.

11) 앞서 서술한 것처럼 이 글은 통상임금과 관련된 종래의 논의방식을 따르지 않고, 어떻게 하면 시간당 일의 대가를 산정하는 것이 합리적이며 타당한지를 검토한다. 이후 이러한 검토내용을 현행 통상임금과 비교해 본다면 통상임금이 시간당 일의 대가로서의 역할을 할 수 있는지 가능해 볼 수 있을 것이다.

12) 대법원 2013. 12. 18. 손고 2012다89399 전원합의체 판결.

실제 연장근로 등이 제공된 때에는 사전에 확정된 통상임금을 기초로 하여 가산임금을 곧바로 산정”할 수 있게 되기 때문이라고 실시하고 있다. 이에 따르면 판례가 보는 통상임금의 개념과 현실, 그리고 그 기능 사이에 괴리가 있다고 판단된다.¹³⁾ 그 이유는 다음의 두 가지이다.

첫째, 현재 근로기준법의 규정상 통상임금은 연장, 야간 및 휴일근로의 경우를 제외하고 실제로 노동이 제공된 경우(내지 실제 노동이 제공되어야 하는 경우)에는 그 대가 산정시 기준임금으로 사용되지 않는다. 연장, 야간 및 휴일근로의 경우도 앞서 문제제기한 바와 같이 가산부분에 대해서만 명시적으로 규정하고 있을 뿐 실제로 노동을 제공한 시간에 대해서 기준임금으로 활용할지 여부에 관해서는 함구하고 있다. 둘째, 소정근로 시간에 통상적으로 제공하는 근로의 가치 ‘평가’는 현재 임금유연화가 가속화되고 성과급 체계가 확대되고 있는 상황에서 ‘사전적’ 평가로 제한할 수 없다. 근로의 결과인 업적도 임금액수에 영향을 미치고 결국 임금액수는 통상적으로 행해지는 근로의 가치를 표상하므로 ‘사후적’ 평가도 포함시킬 수밖에 없다. 사용자와 근로자 간의 비용 및 보상 문제의 예측가능성을 위해서 ‘사전적’인 평가만 고집해야 할 이유도 빈약해 보인다. 연장근로 등의 경우는 근로기준법에서 그 한계를 명확히 하고 있으며 시간에 제약을 두고 있다. 임금은 고정적인 것과 비교정적인 것의 합이라 할 수 있는데, 예측가능성 확보를 위해 비교정적인 것을 배제하는 것은 온전한 임금의 파악을 포기하는 것이다.

(3) 통상임금의 기능

대법원은 “근로기준법은 위와 같이 실제 근로시간이나 근무실적 등에 따라 증감·변동될 수 있는 평균임금의 최저한을 보장하고 연장·야간·휴일 근로에 대한 가산임금, 해고예고수당 및 연차휴가수당 등을 산정하는 기준임금으로서 ‘통상임금’을 규정하고 있다.”고 하면서, “근로자의 연장·야간·휴일 근로가 상시적으로 이루어지는 경우가 드물지 않은 우리

¹³⁾ 김성진, “통상성으로 본 대법원의 통상임금법리”, 『노동법학』 제49호, 한국노동법학회, 2014, 42쪽은 전원합의체판례는 통상임금을 기능적으로 이해하고 있다고 보고 있다.

나라의 현실에서 근로기준법이 위와 같이 통상임금에 부여하는 기능 중 가장 주목되는 것은 그것이 연장·야간·휴일 근로에 대한 가산임금 등을 산정하는 기준임금으로 기능한다는 점이다. 근로기준법은 사용자로 하여금 연장·야간·휴일 근로에 대하여 통상임금의 50% 이상을 가산하여 지급하도록 규정하고 있는데, 이는 사용자에게 금전적 부담을 가함으로써 연장·야간·휴일 근로를 억제하는 한편, 이러한 근로는 법정근로시간 내에서 행하여지는 근로보다 근로자에게 더 큰 피로와 긴장을 주고 근로자가 누릴 수 있는 생활상의 자유시간을 제한하므로 이에 상응하는 금전적 보상을 해주려는 데에 그 취지가 있다.”고 판시하고 있다.¹⁴⁾

판례가 보는 통상임금의 기능은 (i) 연장근로 등에 대한 가산임금을 산정하는 기준임금이 되고, (ii) 사용자에게 대한 금전적 부담을 가하여 시간 외 근로를 억제하며, (iii) 금전적 보상을 해주는 것이다. (i)과 (ii)의 기능을 수행하기 위하여 본질적으로 통상임금이 시간당 소정임금과 동일할 필요는 없다. 가산에 초점이 맞추어 있기 때문이다. (iii)의 경우는 기능이 라기보다 가산의 이유를 설시하고 있다고 보여진다. 즉 금전적 보상이 법정근로시간 내에서 행해지는 근로보다 더 큰 피로와 긴장을 주기 때문에 가산한다는 것이다.

(iii)의 경우를 더 확실히 관찰하고자 한다면 ‘법정근로시간 내에서 행해지는 근로’에 대한 가치 평가가 올바르게 이루어져야 한다. 그런 연후에 가산수당이 덧붙여져야 근로기준법에서 규정하는 정당한 금전적 보상이 될 수 있을 것이다.

(4) 성과급 제도의 도입 등 임금유연화 확대 경향

산업구조와 노동시장이 변화하고 있으므로 기존의 경직적인 연공급 임금체계를 개편하고 직무나 성과 중심의 임금체제로 개편해야 한다는 주장이 있으며, 실제 이에 맞추어 임금구조도 변화하고 있다. 특히 넓은 의미의 성과급제도로도 할 수 있는 성과연봉제와 관련하여 정부는 동기부여, 공정한 보상, 생산성 제고, 인건비 부담 경감, 신규고용촉진 등을 이유로 그 도입필요성을 설명하고 있다.¹⁵⁾

¹⁴⁾ 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

물론 이를 위한 절차적 정당성 확보가 지속적으로 문제되겠지만,¹⁶⁾ 산업계는 현실적으로 성과급 제도의 도입 등 임금유연화가 지속적으로 확대되어 가는 상황에 처해 있다. 성과급은 소정근로에 대한 평가를 그 업적이나 성과와 연동하여 결과가 발생했을 때까지 유보하겠다는 것으로 이해된다. 반대로 말하면 성과급 체계에서는 성과가 나온 후에야 비로소 소정근로에 대하여 제대로 된 가치평가가 가능하다는 것이다.

(5) 소결

결국 작금의 통상임금을 둘러싼 논의의 발생 이유는 통상임금의 문제를 본질적 측면에서 접근하고자 하면 그 기능에 부합하지 않고, 기능적으로 접근하고자 하면 그 본질에 부합하지 않는 모순이 발생하고 있기 때문이라고 봐야 할 것이다.¹⁷⁾ 오히려 통상임금은 그 주요기능에 입각해서 판단하고 정의도 그에 맞추어 이해하는 것이 타당하다고 생각한다. 결국 통상임금은 시간당 일의 대가, 즉 시간당 소정임금이 아니다. 통상임금은 단순히 가산수당을 정하고 각종 수당을 산정할 수 있는 기준임금으로 역할을 할 뿐이다. 따라서 현행 근로기준법 제56조의 규정만으로는 이른바 연장근로 등에 대해 해당근로시간의 근로에 대한 임금지급액수는 규정되어 있지 않다고 보아야 한다. 그렇다면 이를 어떻게 해결할 것인가?

15) 노상현, “공공기관 성과연봉제의 확대와 사회통념상 합리성-서울중앙지방법원 2017. 8. 10. 선고 2016가합26506판결-”, 『노동판례리뷰』 2017, 한국노동연구원, 2018, 42쪽.

16) 김근주, “공공부문 성과연봉제: 도입 절차의 적법성-서울중앙지방법원 2017.5.18. 선고 2016가합566509판결-”, 『노동판례리뷰』 2017, 한국노동연구원, 2018, 40쪽.

17) 김홍영, “통상임금 전원합의체 판결의 의의”, 『노동리뷰』 2014년 2월호, 한국노동연구원, 2014, 21~22쪽에서는 전원합의체판결이 제시하는 “고정성이란 연장근로 등의 가산임금을 산정하는 기준임금으로 기능하기 위해 통상임금이 미리 확정되어 있어야 한다는 요청에서 도출되는 본질적인 성질이라고 논거를 제시한다.”고 서술하고 있다. 사건으로는 결국 고정성은 통상임금이 가지는 기능을 본질적 요소로 보고 요구되는 성질인 것이지, 실제 제공한 시간당 노동에 대한 가치를 표상하는 요소는 아니라고 생각한다.

결국 법원(法源)의 문제로 풀여가지 않을 수 없다. 근로기준법에 규정이 없을 경우에는 일반법인 민법에 의할 것이고 민법에 규정이 없을 경우에는 결국 조리에 의해야 할 것이다.¹⁸⁾ 민법 제1조가 조리를 법원의 하나로 열거하고 있지만, 조리가 법원인가에 대해서는 민법학계에서도 논란이 있다.¹⁹⁾ 조리를 법원으로 보든지 보지 않든지 현행 근로기준법에는 시간당 소정임금에 대하여 명확하게 규정하고 있지 않으므로 필자 자신이 ‘입법자’라면 만들었을 ‘시간당 소정임금’에 대한 산정방식은 어떻게 되는지 서술해 보도록 한다.

다. 시간당 소정임금 산정

시간당 일의 대가, 즉 시간당 근로의 대가에 대하여 지급한 임금이 시간당 소정임금이다. 결국 소정근로에 대한 임금을 소정근로시간으로 나눈 값이라 할 것이다.²⁰⁾ 근로기준법 시행령 제6조 제2항상 시간급 금액으로

18) 민법 제1조는 “민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.”라고 규정하고 있다. 법률용어 사전에 의하면 조리는 다음과 같이 정의 내려진다. “조리는 사물의 성질·순서·도리·합리성 등의 본질적 법칙을 의미한다. 경우에 따라서는 경험칙(經驗則)·공서양속(公序良俗)·사회통념(社會通念)·신의성실(信義誠實)·사회질서(社會秩序)·정의(正義)·형평(衡平)·법(法)의 체계적 조화·법의 일반원칙 등의 명칭으로 표현되는 일도 있다. 그 법원성에 대하여는 긍정설과 부정설이 있다. 아무리 완비된 성문법이라도 완전무결할 수 없다. 따라서 법의 흠결이 있을 경우에는 조리에 의하여 보충하여야 한다. 민법 제1조는 「민사에 관하여 법률의 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다」고 하여 민사재판에서 성문법도 관습법도 없는 경우에는 조리가 재판의 규범이 된다고 명문으로 규정하고 있으므로 조리는 보충적 효력을 가진다고 한다.” (이병태, 『법률용어사전』, 법문북스, 2016)

19) 조리의 법원성과 관련하여 “조리를 형식적인 법원의 하나로 열거하고 있는 제1조는 법질서의 불완전성, 즉 성문법규와 관습법이 민사재판의 기준을 제공하지 못할 수 있음을 전제로 한다. 그런데 법의 흠결이 있더라도 법관은 이를 이유로 재판을 거부할 수 없지만, 그렇다고 하여 자의적인 재판을 할 수도 없는 바, 이러한 경우에 법관 자신이 입법자였다면 만들었을 규칙을 적용하여야 한다. 이러한 규칙이 바로 조리인 것이며, 따라서 조리를 법원으로 보는 것은 무리라고 할 것이다.”라고 하여 법원성을 부정하는 견해도 있다. (지원림, 『민법강의』 제7판, 홍문사, 2008, 15쪽)

정한 임금이나 일급 금액으로 정한 임금의 경우에는 통상임금의 산정방법과 동일할 것이다. 다만 주급이나 월급 금액으로 정해지는 경우에는 차이가 발생한다. 소정근로시간 외 유급으로 처리되는 시간에 있어서 ‘유급’이 시간당 소정임금으로 산정될지 통상임금으로 산정될지 역시 규정상 명백하지 않기 때문이다.²¹⁾

실제 산정을 할 때에는 (i) 소정근로에 대한 임금의 대상범위를 결정하고 (ii) 대상범위에 해당하는 임금항목의 지급방법 및 시기에 따라 환산

20) 근로기준법 시행령 제6조 ② 제1항에 따른 통상임금을 시간급 금액으로 산정할 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 산정된 금액으로 한다.

1. 시간급 금액으로 정한 임금은 그 금액
2. 일급 금액으로 정한 임금은 그 금액을 1일의 소정근로시간 수로 나눈 금액
3. 주급 금액으로 정한 임금은 그 금액을 주의 통상임금 산정 기준시간 수(법 제2조제1항제7호에 따른 주의 소정근로시간과 소정근로시간 외에 유급으로 처리되는 시간을 합산한 시간)로 나눈 금액
4. 월급 금액으로 정한 임금은 그 금액을 월의 통상임금 산정 기준시간 수(주의 통상임금 산정 기준시간 수에 1년 동안의 평균 주의 수를 곱한 시간을 12로 나눈 시간)로 나눈 금액
5. 일·주·월 외의 일정한 기간으로 정한 임금은 제2호부터 제4호까지의 규정에 준하여 산정된 금액
6. 도급 금액으로 정한 임금은 그 임금 산정 기간에서 도급제에 따라 계산된 임금의 총액을 해당 임금 산정 기간(임금 마감일이 있는 경우에는 임금 마감기간을 말한다)의 총 근로 시간 수로 나눈 금액
7. 근로자가 받는 임금이 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정한 둘 이상의 임금으로 되어 있는 경우에는 제1호부터 제6호까지의 규정에 따라 각각 산정된 금액을 합산한 금액

21) 하갑래, 앞의 책, 234쪽에서는 “공민권행사에 대해서는 관련법에 규정이 있으면 임금이 지급된다. 이 때 관련법의 표현인 ‘휴무 또는 휴업으로 보지 않는다’는 유급 나아가서 통상임금을 의미하는 것으로 해석할 수 밖에 없다. 또한 당사자가 유급으로 정하면서 산정기초를 밝히지 않으면 이 역시 통상임금으로 해석할 수 밖에 없다. 휴가나 공민권행사처럼 실제로 근로를 제공치 않은 경우, 근로한 것으로 간주할 수는 있지만, 당연히 통상임금으로 해석할 근거는 약하다. 뿐만 아니라 근로를 제공하는 경우에도, 유급의 산정기초를 당사자가 자율적으로 결정하는 것을 인정하는 해석도 있음을 감안하면, 통상임금을 적용해야 한다는 데 대해 강행적 효력을 부여하기 어렵다. 해당 근로조건에 대해 통상임금으로 지급된다는 의미가 명확해지도록 법에 명시하는 것이 바람직해 보인다.”라고 하고 있다.

하여 계산한다. (i)의 과정은 결국 임금성의 문제로 귀결될 것이고, (ii)의 과정은 사전에 산정가능한지 여부, 즉 산정가능성의 문제로 귀착될 것이다.

(1) 소정근로에 대한 임금 해당성

소정근로에 대한 임금에 해당하는지 여부의 문제는 기존의 임금성 문제로 해결하면 족하다고 생각한다. 어떠한 항목이 소정근로에 대한 대가 관계를 가지는지는 소정근로시간에 통상적으로 제공하기로 정한 근로자의 근로의 가치를 어떻게 평가하고 그에 대하여 얼마의 금품을 지급하기로 정했는지를 기준으로 전체적으로 판단해야 한다.

이에 대해 대법원은 앞서 살펴 본 바와 같이 “통상임금이 위와 같이 근로자가 사용자와 사이에 법정근로시간의 범위에서 정한 근로시간(이하 ‘소정근로시간’이라고 한다)을 초과하는 근로를 제공할 때 가산임금 등을 산정하는 기준임금으로 기능한다는 점을 고려하면, 그것은 당연히 근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하는 근로의 가치를 금전적으로 평가한 것이어야 하고, 또한 근로자가 실제로 연장근로 등을 제공하기 전에 미리 확정되어 있어야 할 것이다.”라고 하고 있다.²²⁾ 그러나 이러한 해석은 통상임금의 기능만 강조한 해석일 뿐 성과급 등 근로에 대한 가치 평가가 근로 제공 후로 유보되어 있는 경우에는 이를 반영하지 못한다는 문제점이 있다. 사전에 그 지급여부나 액수가 정해지지 않더라도 그 평가방법이 정해져 있다면 소정근로에 대한 임금 해당성이 있다고 할 것이다. 대법원의 동일한 판결에서 이러한 해석의 단초가 보이는 설시가 있다. 즉, “소정근로의 대가가 무엇인지는 근로자와 사용자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하기로 정한 근로자의 근로의 가치를 어떻게 평가하고 그에 대하여 얼마의 금품을 지급하기로 정하였는지를 기준으로 전체적으로 판단하여야 하고, 그 금품이 소정근로시간에 근무한 직후나 그로부터 가까운 시일 내에 지급되지 아니하였다고 하여 그러한 사정만으로 소정근로의 대가가 아니라고 할 수는 없다.”라는 설시이다.²³⁾ 사전에 산

²²⁾ 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

²³⁾ 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

정되지 않거나 근무 직후에 지급되지 않았다하더라도 소정근로의 대가가 될 수 있는 여지가 있음을 스스로 밝히고 있다.

임금성이 있는 항목이라 하더라도 소정근로에 대한 임금이 문제되는 경우이므로 소정근로 외에 해당하는 근로에 대한 임금은 제외될 것이다. 대표적인 경우가 연장근로수당, 휴일근로수당 등이 될 것이다. 이는 임금성을 가지지만 소정근로시간 외의 근로에 해당하므로 제외된다. 통상임금의 구성항목과 비교해 볼 때, 특히 근무실적 평가를 토대로 지급 여부나 지급 액수가 달라지는 임금인 성과급이나 개념적으로 후불임금의 성격을 띠는 퇴직금 등이 문제될 수 있다. 여기서는 성과급과 퇴직금에 관해서 논해 보고자 한다.

(가) 업적 내지 성과급

임금은 근로의 대가, 즉 근로를 제공한 것에 대한 반대급부로 지급하는 것이다. 성과급은 그 지급 내지는 액수가 근무실적 평가를 토대로 하기 때문에 산정시기에 따라 지급여부 및 액수가 유동적이게 된다. 그렇다고 항상 임금성이 부정되는 것은 아니다.²⁴⁾ 임종률 교수도 “근로자 개인의 업무 실적, 성과에 따라 차등적으로 지급하는 포상금, 성과급은 의례적 호의적 급여가 아니라 근로의 대가”라고 평가하고 있다.²⁵⁾

임금은 당사자간 근로계약에 의하여 소정근로에 대하여 그 대가로 약정되게 된다. 그러나 임금인 성과급의 경우는 그 지급여부와 액수를 근로의 결과와 결부지어 지급하게 된다. 비록 지급여부나 액수가 사전에 확정되어 있지는 않지만 그 기준이 사전에 확정되어 있는 경우 임금성은 여전히 유지된다.

앞서 살펴 본 바와 같이 임금의 유연성 확대되고 있고 근로의 효율성 제고를 위한 수단으로 성과, 업적급의 비율이 증가하고 있는 것이 현실

24) 김정환, “성과급의 의의와 법적 성격에 관한 연구”, 『노동연구』 제31집, 고려대학교 노동문제연구소, 2015, 122~124쪽에서는 임금성이 있는 성과급인 임금체계 내 성과급과 임금성이 없는 성과급인 임금체계 외 성과급으로 구분하고 있다. 순수한 변동형 실적급과 새로운 형태의 상여금을 신설한 경우 임금성이 인정되는 경우가 있다고 한다.

25) 임종률, 『노동법』 제15판, 박영사, 2017, 398쪽.

이다. 1시간당 노동의 가치는 당사자가 미리 정하는 것이 가장 전형적인 방법이고 산정에 있어서도 수월하지만, 그 결과인 업적과 성과를 연결지어 평가하는 것이 일상적인 상황이 되기에 이르렀다.

성과 중심의 임금체계 도입은 업무의 효율성을 높이자는 것이고, 세부적으로는 동기부여, 공정한 보상, 생산성 제고, 인건비 부담 경감, 신규고용촉진 등을 지향한다. 여기서 공정한 보상이라는 것은 노동에 대한 평가를 개별화하고 개별적으로 평가된 노동가치가 보상되는 것이다. 성과가 달라지면 노동의 질이 달라졌다고 볼 수 있다. 성과는 노동의 질을 표상하기 때문이다. 소정근로의 질과 직접관련성이 있는 부분이라고 한다면 시간당 소정임금의 대상범위에 포함되어야 하는 것은 자명하다. 다만 이는 후술할 산정가능성의 문제 내지 정산제도의 필요성 문제를 야기할 것이며, 시간당 소정임금의 유동성 문제를 발생시켜 예측가능성의 약화를 가져올 수 있다.

(나) 퇴직금

퇴직금의 법적 성질과 관련하여서는 공로보상설, 생활보장설, 후불임금설 등이 대립하였다. 이에 대해서는 다음과 같이 소개되고 있다. 공로보상설은 계속근로를 통한 기업에의 공로를 보상하기 위한 급여로 보는 견해이고, 생활보장설은 퇴직 후의 생활안정을 보장하기 위한 급여로 보는 견해이며, 후불 임금설은 재직중의 전체 근로에 대하여 퇴직 시에 일시에 지급하는 임금으로 보는 견해이다.²⁶⁾ 판례는 누진제 퇴직금에 대하여 후불임금으로서의 성격 이외에 공로보상으로서의 성격과 사회보장적 급여로서의 성격도 아울러 가진다고 본 바 있으나, 이는 누진제 퇴직금의 경우에 해당하는 사항이다.²⁷⁾ 퇴직금은 후불임금이라 하여 “근로자의 근로제공에 대하여 그때그때 지급하여야 할 임금의 일부를 축적한 것이라는 의미가 아니라, 재직 기간 전체 근로에 대하여 포괄적으로 책정, 지급되는 임금, 즉 노동관계가 종료되는 때에 비로소 지급 의무가 발생하는 임금”이라는 의미라고 해석한다.²⁸⁾

²⁶⁾ 임종률, 앞의 책, 561쪽.

²⁷⁾ 대법원 1995. 10. 12. 선고 94다36186 판결.

필자는 퇴직금이 후불임금으로서 성질을 가지기 때문에 소정근로에 대한 대가로서 산정범위에 들어가며 시간당 노동의 가치를 표상한다고 생각한다.²⁹⁾ 비록 노동관계가 종료되는 때에 비로소 지급 의무가 발생하지만 소정근로와 가치적으로 그 대가관계로서 연결되어 있다. 따라서 시간당 소정임금의 대상범위에 포함되어야 한다. 다만 업적 내지 성과급과 마찬가지로 후술할 산정가능성의 문제를 야기한다.

(2) 산정가능성

소정근로에 대하여 임금해당성이 있다하더라도 시간당 소정임금의 산정이 필요한 시기에 산정이 불가능하다면 계산 시 배제될 수밖에 없다. 예를 들어 앞에서 살펴본 바와 같이 성과급의 경우 근로의 결과와 관련되므로 근로의 대가라는 것은 부정할 수 없다. 따라서 산입대상에 해당하고 이를 산정하여야 하는데 산정 당시에 그 결과가 나오지 않은 경우에는 원천적으로 산입이 불가능하다. 다만 최소한의 지급정도가 결정되어 있다면 이를 산정하여 계산하여야 할 것이다. 이를테면 일정한 근무일수를 채워야 지급되는 근속수당과 같은 경우는 일정 근무일수라는 조건이 성취되어야 지급여부가 결정되게 된다. 이 경우 그 조건의 성취여부와 시간당 소정임금의 산정시기에 따라 산정시 포함여부가 결정될 것이다. 다만 일정 근무일수를 기준으로 지급액이 달라지되 적어도 일정액의 지급은 확정되어 있는 경우 그 최소한도로 확정된 범위에서는 시간당 소정임금 산정시 산입되어야 할 것이다.

시간당 소정임금의 산정범위에 해당하는 항목은 가능한 산입할 수 있도록 해야 근로자보호를 취지로 하는 근로기준법의 목적에 적합하다. 이를 이른바 ‘최대산입의 원칙’이라 부를 수 있을 것이다. 임금 항목, 지급

28) 임종률, 앞의 책, 561쪽.

29) 2018년도 6월 22일 개최된 한국비교노동법학회·한국노동법학회 공동 학술대회에서 당해 논문이 발표되었는데 다음과 같은 의문이 제기되었다. 필자의 시간당 소정임금 산정방법을 전제로 하더라도 퇴직금이 그 대상에 들어가는 것이 맞느냐는 것이었다. 소정근로에 대하여 양 당사자가 정한 소정의 대가라기보다 법에서 규정한 법정 대가이기 때문이다. 그러나 법에서 당연히 지불하여야 하는 것으로 규정한 경우 이는 소정 대가에 포함된다고 봐야 할 것이다.

기준, 방법 등의 다양화로 인하여 그 산정이 어렵기는 하지만 소정근로의 대가인 소정임금을 최대한 반영하여 계산하고 이후 그 조건이 성취되었을 때에는 이를 전부 산입하여 계산하는 것이 임금유연화 시대에 대처하는 합리적 귀결이라고 생각한다.

후불임금인 퇴직금의 경우 그 산정방법을 두고 문제가 된다. 근속년수가 1년이 지나지 않은 근로자의 경우에는 퇴직금이 발생하지 않으므로 근속년수 1년 이상인 근로자에 대하여 산정가능성이 문제된다. 퇴직금은 평균임금을 기준으로 산정하고 평균임금은 사전적 기준임금이 아니라 사후적인 기준임금이므로 아직 퇴직을 하지 아니한 시점에서는 산정이 불가능하다. 평균임금은 유동적이라 평균임금이 통상임금보다 적은 경우 통상임금을 기준으로 산정하게 된다. 따라서 ‘최대산입의 원칙’에 입각하여 통상임금을 기준으로 산정한다. 다만 이 글의 논의에서 논리적 전제는 시간당 소정임금과 통상임금이 구별되고 별도 산정가능하다는 것이다. 현재의 통상임금 체계에서는 통상임금을 시간당 소정임금으로 본다면 통상임금 계산시에 통상임금을 계산하여 산입하는 경우로 계산상 논리적 모순이 발생하고, 종국적으로는 계산이 불가능해진다. 다만 정산제도를 두는 경우라면 통상임금으로 계산하여 산정하고, 이후 평균임금을 반영하여 정산할 수 있다.

(3) 정산 방식의 도입가능성

앞서 산정가능성이 문제되는 경우는 시간당 소정임금의 산정이 필요한 때 업적이나 성과의 평가 시기가 차후로 예정되어 있어 산정이 필요한 시기에 산정이 불가능하게 되는 경우였다. 그러나 일정한 조건이 성취되거나 업적, 성과가 발생하고 이를 평가한 이후에는 산정이 가능하다. 그렇다면 하면 사후에 다시 시간당 소정임금을 정확히 계산하여 정산하는 방법은 현행법상 불가능한 것인가?

대개 임금체계는 1년을 단위로 변동이 있고 이에 따르면 통상임금의 경우도 1년을 단위로 변경되게 된다. 이는 1년을 단위기간으로 정산하면 일반적으로 시간당 소정임금이 정확히 계산할 수 있다는 것이다. 앞서 살펴보았듯이 ‘소정’의 의미를 지급여부 및 액수가 사전에 확정되어 있는

경우뿐만 아니라 지급조건 및 평가방법이 사전에 확정되어 있는 경우까지 포함한다고 봐야 한다. 다만 그 산정이 어려울 뿐이다. 판례는 통상임금에 사전확정성 내지 고정성을 요구하여 미리 확정가능하도록 하고 있고 예측가능성을 높이려고 하고 있지만, 이는 사전적 평가와 사후적 평가가 동시에 필요한 현대 노동의 가치 평가 현실과는 맞지 않는다. 또한 사후적 평가가 배제된 반쪽 짜리 노동 가치 평가일 뿐이다. ‘소정근로’에서 ‘소정’의 의미를 좁게 해석함으로써 연장 근로 등에서 근로자에게 정당한 보상을 받지 못하게 하는 것은 근로자 보호를 위한 법인 근로기준법의 취지에 맞지 않는다.

근로기준법 제43조 제1항에 의하면 임금은 그 전액을 지불하여야 한다. 또한 동법 동조 제2항에 의해서는 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 한다. 전액불의 원칙은 근로자가 정당하게 받아야 할 임금을 지급가능한 시기에 전액 지불해야 하는 것으로 이해할 수 있다. 그렇다면 1년의 단위기간을 두어 시간당 소정임금을 산정하고 연장 근로 등에 대해서 추가적으로 지급할 액수를 산정하여 지급하는 정산지급도 가능하다고 생각한다. 또한 정기불의 원칙과 관련하여서는 우선적으로 현행의 통상임금 체계로 산정하여 매월 1회 이상 지급하는 것으로 하고 완전한 시간당 소정임금이 산정되었을 때 차액을 계산하여 정산, 지급할 수 있다고 생각한다.

현행의 통상임금에 대한 정의와 이에 대한 대법원의 해석론은 정당한 임금을 산정하고 이에 대해 지급하려는 노력을 하는 것이 아니라 사전확정성 내지 고정성 등의 요건을 추가하여 근로자에게 지급하여야 할 시간당 소정임금 자체를 통상임금으로 축소시키고 확정시켜 전액을 지불함으로써 의제하는 것에 불과하다 할 것이다.

Ⅲ. 논의의 실익과 한계

이 글에서 시간당 소정임금을 구하려는 시도와 결과는 논의의 실익과 한계를 겸유하고 있다.

1. 시간당 소정임금 논의의 실익

시간당 소정임금의 산정에 대한 논의는 다음과 같은 실익이 있다고 생각한다. 첫째, 통상임금을 시간당 소정임금으로 활용하고 있는데, 이는 정당한 임금계산법이 아니다. 시간당 소정근로에 대한 가치 평가인 시간당 소정임금은 사전에 지급여부나 액수가 평가될 수 있게 확정될 수 있지만, 임금성을 가지는 업적/성과급 등은 일정 기간의 근무실적 평가를 토대로 지급여부나 액수가 사후에 결정될 수 있다. 사전적 평가와 사후적 평가를 거쳐 산정된 시간당 소정임금이야말로 온전한 시간당 소정임금이다. 두 번째, 시간당 소정임금을 인정하는 경우 통상임금과 별개로 논의될 수 있기 때문에 근로기준법상 임금성 여부와 산정가능성 여부로 논의가 단순화된다. 지금까지의 통상임금 논의에서는 임금성 요건과 통상성 요건이 서로 착종되어 지나치게 복잡다단하였다.³⁰⁾ 요건 및 판단기준을 단순화하는 것이 임금체계의 복잡화 경향을 방지할 수 있는 방안이다.³¹⁾ 세 번째로 임금이분설을 폐기한 현재의 판례의 태도와 정합성을

30) 권혁, “통상임금의 고정성에 관한 법리 재평가”, 『노동법논총』 제28호, 한국비교노동법학회, 2013, 254쪽에서는 “고정성 요건은 근로기준법 시행령에 근거한 것이 아니다. 법원의 해석론을 통해 형성된 개념이다.”라고 하고 있다. 이처럼 근로자의 임금수준과 직결되는 통상임금을 판단하는 요건이 법령에 근거하지 않고 판례의 해석을 통해 인정되고 있다.

31) 허재준, “최저임금 제도의 개선”, 『전환기의 노동과제』, 오래, 2017은 최저임금에 있어서 산입범위의 간단명료화를 강조하고 있다. 사건으로는 최저임금 뿐만 아니라 통상임금에도 마찬가지라고 생각한다. 당해 글에서는 “최저임금에 산입되는 임금의 범위를 간단명료하게 바꾸어야 한다. 현행 최저임금 산입범위는 근로자, 사용자, 근로감독관 모두 판단에 어려움을 겪을 정도로 명확성이 낮아 개선 필요성이 존재한다는 점이다. 최저임금의 산입범위를 실질적으로 지급되는 임금과 부합시키고 단순·명확화하는 것이 법 준수를 용이하게 한다는 점이다. 준수를 제고는 다른 무엇보다 근로자와 사용자가 최저임금 준수 여부를 손쉽게 판단할 수 있게 하는 데에 있다. 최저임금을 준수하지 않으면 형사처벌 대상이 된다. 그러므로 산입범위를 구체적으로 간명하게 하는 것이 법률강제의 취지에 부합하고 그래야만 실효성을 높일 수 있을 것이다. 우리 사회에서 일반화되어 있는 임금지급 단위인 1개월 단위로 지급하는 통상임금과 일치시키는 것이 좋다. 위와 같은 기준을 택하는 경우 고정상여금처럼 1개월 초과하는 주기로 지급되는 금품은 통상임금에는 포함되지만 최저임

가지게 된다. “현행 실정법하에서는 임금을 근로의 대가, 즉 ‘근로자가 자신의 노동력을 사용자의 지휘, 처분하에 두고 제공한 근로에 대한 대가’라고 할 것이라는” 논지를 일관할 수 있다.³²⁾ 임금성이 있는 항목들을 사전확정성 내지 고정성이라는 기능적 이유로 재평가하여 통상임금성 여부와 결부시키는 것은 맞지 않다. 네 번째로 근로관계, 특히 임금과 관련하여 사용자의 우월적 지위에 입각한 임의성을 배제하고자한 근로기준법과 근로자성에 대한 판례의 태도를 견지할 수 있게 된다. 근로기준법은 명칭에 의하여 임금성을 임의로 배제하는 것을 방지하고자 하고 있고, 판례는 사용종속관계 판단 중 임금관련 요소와 관련하여서는 더욱 신중을 기하고 있다. 따라서 통상임금성 여부 판단시의 재직지급요건 등의 문제도 임금성 문제와 구별하여 파악한다면 임금성 판단에까지 확대오용되는 것을 방지할 수 있을 것이다.³³⁾ 다섯째, 시간당 소정임금은 정당한 ‘일의 대가’를 의미하므로 연장근로시간에 대해서도 시간당 소정임금은 보장되어야 한다. 그렇기 때문에 최저임금이 적용되는 소정근로시간과 마찬가지로 연장근로시간에 대해서도 최저임금법은 규정이 없더라도 당연히 적용되어야 마땅하다.³⁴⁾ 더불어 통상임금과 관련하여서는 현재의 통상임금을 시간당 소정임금으로 보기에 현재의 통상임금 개념 정의상 어려워 보인다. 그렇다면 입법상의 불비로 보아서 시간당 소정임금을 반영할 수 있는 입법적 보완이 필요하다.

2. 한계

금에는 산입되지 않게 된다.”라고 지적하고 있다.

32) 대법원 1996. 10. 25. 선고 96다5346 판결.

33) 하갑래, 앞의 책, 238쪽은 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결의 “재직여부법리가 임금성 판단에까지 확대될 개연성을 배제하기 어렵”다는 견해를 제시하고 있다.

34) 김홍영 교수는 연장근로 시간에 대해서 최저임금이 적용되어야 하는지 최저임금법에는 명확하게 규정이 없다고 지적하면서 만약 필자의 논지에 따라 ‘일의 대가’ 측면에서 본다면 최저임금액보다 낮은 시급을 기준으로 연장근로수당을 계산하는 것은 부적절하다고 서술하고 있다. 이러한 견해에 필자도 동의한다. (김홍영, “일의 대가에 대한 토론문”, 『2018년도 한국비교노동법학회·한국노동법학회 공동 학술대회 자료집』, 2018, 28쪽)

한계점으로는 첫째, 시간당 소정임금과 통상임금이 구별된다는 전제하에서 월급의 방식으로 지급하는 경우 미지수가 두 개인 이원일차방정식이 되어 역산 내지 환산이 불가능해지는 문제가 발생한다. 이는 현행 통상임금의 문제가 결국 역산 내지 환산가능성의 문제로 귀결되는 것과 마찬가지이다. 김홍영 교수는 “주휴수당의 계산 때문에 시간급이 ‘소정근로시간의 시간당 대가로서의 임금’을 제대로 반영하지 못하고”있다고 하면서 “그렇게 불명확한 시간급 지표를 기준으로 계산된 임금액으로 소득수준을 평가하고, 소득수준을 다시 불명확한 시간수로 나누어 최저임금의 시간급을 제시하고 있어, 계산상 여러 왜곡이 발생”한다고 지적하고 있다.³⁵⁾ 이는 최저임금과 관련하여 지적하고 있는 사항이지만 주급이나 월급의 형태로 지급되는 임금항목의 경우에는 모두 동일한 문제점이 발생한다.³⁶⁾ 두 번째, 시간당 소정임금이 가변적이 된다.³⁷⁾ 임금 산정의 조건이 산정가능하게 현실화되는 이후와 그 이전의 시간당 소정임금이 달라질 수 있다. 세 번째, 만약 정산방식을 취하게 되는 경우라면 시간당 소정임금 지급의 정당성은 확보되나 예측가능성이 축소되고 거듭 산정해야 하는 불편이 초래될 수 있다.³⁸⁾

35) 김홍영, “최저임금 비교대상임금의 조정범위”, 『최저임금법의 쟁점과 과제』, 한국노동법학회, 2018. 36쪽.

36) 강성태, “새 정부의 노동·사회보장 분야 주요 개혁과제”, 『노동법연구』 제43호, 서울대학교노동법연구회, 관악사, 2017, 13쪽에서는 주휴일의 무급화를 주장하기도 한다. “현행 제도는 최저임금액에 관한 계산의 복잡성 때문에 일반인의 예측가능성이 떨어지는 등 기술적 측면에서도 문제점이 있다. 주휴일의 무급화를 통한 월 소정근로시간과 월 최저임금액의 명확화, 생계비 통계 분석의 정밀화, 최저임금 산입 임금의 범위 명확화 등은 새 정부의 의지만 있다면 출범 초기에 개선할 수 있는 과제들이다.”라고 지적하고 있다.

37) 김희성, “통상임금에 관한 법적 문제점과 개선방안”, 『노동법논총』 제28호, 한국비교노동법학회, 2013, 292~293쪽에서는 “도구로서의 통상임금이 고정되어 있지 않다면 통상임금으로 산정되는 임금들이 가변적이 되어 결국은 임금산정기초가 흔들리게 될 것이다.”라고 있다. 이러한 지적은 이 글에서 제시한 시간당 소정임금 산정방안과 정산방식에도 동일하게 적용될 것이다.

38) 도재형, “통상임금 전원합의체 판결의 검토”, 『노동법연구』 제36호, 서울대학교 노동법연구회, 2014, 180쪽에서는 전원합의체 판결의 긍정적 효과로서 “일정 정도의 예측가능성을 확보”했다는 점을 꼽고 있다.

IV. 결론

현행 근로기준법 제56조에서는 연장·휴일근로시 임금의 할증, 즉 통상임금의 100분의 50 이상의 가산에 대해서만 규정하고 있을 뿐, 연장·휴일근로로 인하여 시간외로 근로한 해당시간에 대한 임금지급액수에 대해서는 명확하게 규정하고 있지 않다. 현재 해석론이나 판례는 통상임금을 활용하여 이를 지급하고 있다. 그러나 통상임금은 이른바 기준임금으로서 근로기준법에서 그 대상사항을 한정적으로 규정하고 있으므로, 이를 확대해석할 것은 아니다. 근로기준법상의 규정이 없으므로 민법에 의하여야 하고, 종국적으로는 민법 제1조에 근거하여 이른바 조리로서 해결할 수밖에 없다.

해당 시간외 근로에 대한 임금지급은 시간급으로 지급되어야 하므로 시간당 일의 대가, 즉 시간당 임금이 산정되어야 가능하다. 이 경우 시간당 임금은 소정근로를 기준으로 하므로 소정근로에 대한 시간급 임금, 이른바 ‘시간당 소정임금’의 산정이 문제된다.

이 글에서 시간당 소정임금을 산정하고 도출하고자 하는 시도는 시간당 소정임금을 합리적이고 타당하게 도출하는 것이 가능하냐에 있다. 만약 도출과정상에 논리적 비약이나 오류, 합리, 타당성이 결여되었다면 당해 과정은 실패한 것이다. 다만 논리적 오류에 의하여 시간당 소정임금의 산정에 실패하더라도 그것이 가지는 문제의식은 향후 통상임금이나 최저임금의 논의에서 나름의 의미를 가지길 기대한다.

시간당 소정임금은 소정근로에 대한 임금을 의미한다. 결국 소정근로에 대한 임금을 소정근로시간으로 나눈 값이라 할 것이다. 실제 산정을 할 때에는 (i) 대상범위의 확정, (ii) 산정가능성의 검토 두 단계로 구분될 것이다. 그리고 산정가능성의 문제는 정산절차를 운영할 것인지와 관련된다. (i)의 과정은 결국 임금성의 인정 문제로 귀결될 것이고, (ii)의 과정은 사전에 계산 가능한지 여부, 즉 산정가능성이 문제될 것이다. (i)의 대상범위를 논할 때 넓은 의미에서 소정근로에 대한 대가면 족하기 때문에 소정근로의 성과나 결과와 연동되는 임금성을 가지는 성과급 등도 포함된다고 봐야 하며, 후불임금인 퇴직금도 포함되어야 한다. 다만

(ii)의 과정에서 산정가능한지가 검토되어야 하고 일명 ‘최대산입의 원칙’에 입각하여 계산하여야 한다. 그리고 시간당 소정임금의 완전한 보상을 위하여 정산절차를 운영하여야 한다.

이 글에서 시간당 소정임금을 구하려는 시도와 결과는 그 의미와 한계를 점유하고 있다. 당해 논의가 가지는 의미는 다음과 같다. 시간당 소정임금으로의 체계 개편은 첫째, 임금성 여부 문제와 산정가능여부 문제로 논의가 단순화된다는 점이다. 지금까지 통상임금 논의에서 임금성과 통상성의 요건이 착종되어 지나치게 복잡다단하였다. 이는 임금체계나 항목의 복잡성을 조장하는 원인으로 작용하고 있다. 두 번째로 임금이분설을 폐기한 현재의 판례의 태도와 정합성을 가지게 된다. 세 번째로 근로관계, 특히 임금과 관련하여 사용자의 우월적 지위에 입각한 임의성을 배제하고자한 근로기준법과 근로자성에 대한 판례의 태도를 견지할 수 있게 된다. 근로기준법은 명칭에 의하여 임금성의 임의로 배제하는 것을 방지하고자 하고 있고, 판례는 사용종속관계 판단 중 임금관련 요소와 관련하여서는 더욱 신중을 기하고 있다. 따라서 재직지급요건 등의 문제도 이러한 관점에서 접근하면 사용자의 악용가능성을 제한할 가능성이 있다고 보여진다. 네 번째로 현행 최저임금법에 명확한 규정이 없다하더라도 일의 대가 측면에서 보았을 때 소정근로시간과 마찬가지로 연장근로시간에 대해서도 당연히 최저임금법이 적용되어야 하는 것이 마땅하다는 점이다.

반면 한계점으로는 첫째, 시간당 소정임금이 통상임금과 다르기 때문에 월급의 방식으로 지급하고 있는 경우 미지수가 두 개인 이원일차방정식이 되어 역산이 불가능해지는 문제가 발생한다는 것이다. 이는 현행 통상임금의 문제가 결국 역산 내지 환산가능성의 문제로 귀결되는 것과 마찬가지로이다. 두 번째, 시간당 소정임금이 가변적이 된다. 임금 산정의 조건이 산정가능하게 현실화되는 전후를 기준으로 시간당 소정임금이 달라진다. 정산방식을 취하게 되는 경우 임금 지급 시기가 나뉘게 되고 계산 등이 번거로워지게 된다.

주제어: 일의 대가, 정당한 대가, 소정임금, 통상임금, 근로기준법 제56조

참고문헌

- 강성태, “새 정부의 노동·사회보장 분야 주요 개혁과제”, 『노동법연구』 제43호, 서울대학교 노동법연구회, 관악사, 2017.
- 권 혁, “통상임금의 고정성에 관한 법리 재평가”, 『노동법논총』 제28호, 한국비교노동법학회, 2013.
- 김근주, “공공부문 성과연봉제: 도입 절차의 적법성-서울중앙지방법원 2017.5.18. 선고 2016가합566509판결-”, 『노동판례리뷰』 2017, 한국노동연구원, 2018.
- 김성진, “통상성으로 본 대법원의 통상임금법리”, 『노동법학』 제49호, 한국노동법학회, 2014.
- 김정환, “성과급의 의의와 법적 성격에 관한 연구”, 『노동연구』 제31집, 고려대학교 노동문제연구소, 2015.
- 김홍영, “통상임금의 입법적 과제”, 『노동법학』 제48호, 한국노동법학회, 2013.
- _____, “통상임금 전원합의체 판결의 의의”, 『노동리뷰』 2014년 2월호, 한국노동연구원, 2014.
- _____, “최저임금 비교대상임금의 조정범위”, 『최저임금법의 쟁점과 과제』, 한국노동법학회, 2018.
- 김희성, “통상임금에 관한 법적 문제점과 개선방안”, 『노동법논총』 제28호, 한국비교노동법학회, 2013.
- 노상현, “공공기관 성과연봉제의 확대와 사회통념상 합리성-서울중앙지방법원 2017.8.10. 선고 2016가합26506판결-”, 『노동판례리뷰』 2017, 한국노동연구원, 2018.
- 도재형, “통상임금 전원합의체 판결의 검토”, 『노동법연구』 제36호, 서울대학교 노동법연구회, 2014.
- 박은정, “통상임금 산정을 위한 기준시간”, 『노동정책연구』 제13권 제4호, 한국노동연구원, 2013.
- 이병태, 『법률용어사전』, 법문북스, 2016.
- 임종률, 『노동법』 제15판, 박영사, 2017.
- 지원림, 『민법강의』 제7판, 홍문사, 2008.
- 하갑래, 『근로기준법』 제30판, (주)중앙경제, 2018.
- 허재준, “최저임금 제도의 개선”, 『전환기의 노동과제』, 오래, 2017.

<Abstract>

Reward of Labor

— the Calculation and Legal Meaning of “Specifically
Agreed Wages” —

Chang, Woo-Chan^{*}

Generally when a employee makes extended work, an employer pays additional 50 percent or more of the ordinary wages for the extended work ‘in addition to the ordinary wages’. But The article 56(1) of Labor Standard Act does not states ‘in addition to the ordinary wages’. This article just states that “An employer shall pay additional 50 percent or more of the ordinary wages for extended work (work during the hours as extended pursuant to Articles 53 and 59 and the proviso of Article 69).” There is no ‘in addition to the ordinary wages’ in this provision.

The purpose of this study is designed to discuss the calculation and legal meaning of what we call “Specifically Agreed Wages”. The term ‘Specifically Agreed Wages’ is for reasonable reward of work. These wages mean the amount calculated by dividing the total amount of wages paid during specifically work hours in agreement. This concept depends on the belief that reward of extended hour work should be the same as one of the specifically work hour.

The followings are the characteristics of the term ‘Specifically Agreed Wages’ in comparison of Ordinary wages. First, the standard of determining Specifically Agreed wages is simpler than that of ordinary wages as regards the concept and scope. Secondly, the

^{*} Assistant Professor, Gyeongnam National University of Science and Technology.

concept of Specifically Agreed Wages is consistent with the Supreme Court's decision against the theory of wage dichotomy. Thirdly, this concept can restrict the abuse of an employer more efficiently than Ordinary wages.

Key Words: Reward of Labor, Reasonable Reward of Work, Specifically Agreed Wages, Ordinary wages, The article 56(1) of Labor Standard Act